

RESUMO DE DIREITOS HUMANOS

Prof. Wilson José Vinci Júnior

Resumo da aula:

A origem dos direitos humanos remonta à própria existência dos seres humanos.

Em sendo direitos inerentes e inatos a todos os indivíduos, os direitos humanos têm sua origem na própria existência da espécie humana.

Porém, os direitos humanos se tornaram mais difundidos e conhecidos especialmente a partir do surgimento do Estado de Direito.

O **Estado de Direito**, tem como marco histórico o advento da Revolução Francesa, que eclodiu com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789.

O Estado de Direito rompeu com o antigo regime denominado **Estado Absolutista** (que vigorou na Europa entre os séculos XVI e XIX), que concentrava os poderes nas mãos do Monarca. Não havia a chamada tripartição de poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário – sendo que cada “poder” do Estado¹, além de sua função típica, também tem por atribuição atípica fiscalizar o outro “poder” – sistema de freios e contrapesos). No Absolutismo, havia forte influência da religião no Estado, sendo que o Monarca era considerado um “representante” de Deus na Terra. Disso decorre a chamada fase da irresponsabilidade do Estado pelos seus atos, afinal, como Deus é um ser perfeito superior aos indivíduos, o Monarca, que era seu representante, também era considerado um ser que não errava (*the king can do no wrong* – o rei não erra), o que não gerava qualquer responsabilização pelos seus atos (repare aqui a interlocução com o Direito Administrativo). Este contexto representava um fértil campo para o abuso do poder estatal pelos seus representantes. Este é o ponto de contato com a disciplina de Direito Administrativo, mais precisamente no assunto responsabilidade civil do Estado.

Com o fim das monarquias absolutistas, surgiu o chamado **Estado Liberal (com o início também do Estado de Direito)**. O Estado Liberal tinha por objetivo proteger o indivíduo do abuso do poder estatal. Já pela expressão Estado de Direito, temos que pela primeira vez na história o mesmo Estado que elabora as leis (por meio do Legislativo) se submete a elas. No Estado Liberal,

¹ Tecnicamente, o correto é se falar em “funções” do Estado, e não em “poderes” estatais, afinal, o poder do Estado é uno: determinar o comportamento do indivíduo. Portanto, o correto seria falar que o poder do Estado é dividido nas funções (e não poderes) executiva, legislativa e judiciária. Porém, como as expressões “Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário” já estão consagradas na linguagem coloquial e pelo fato de que aqui estamos a tratar de um resumo de aula, preferimos utilizar estas expressões, fazendo a ressalva do termo tecnicamente correto.

houve também a separação do Estado da Religião, constituindo o Estado Laico (que não possui nenhuma religião oficial, porém protege todas as formas de religião existentes – interlocução com o direito constitucional). No campo do Direito Administrativo, a irresponsabilidade estatal foi substituída pela responsabilidade civil do Estado, a exemplo do que ocorria com os particulares que causassem dano a alguém.

A vontade pessoal do Monarca, que no Estado Absolutista representava o ápice do ordenamento jurídico, foi substituída pela vontade do povo, verdadeiro titular do poder estatal, que expressava sua vontade por meio da lei, elaborada por representantes eleitos no Poder Legislativo.² Nesta fase, o poder estatal (que é o poder de determinar o comportamento dos indivíduos), que antigamente se resumia à vontade pessoal do Monarca, passou a ser limitado por um **documento com força política e jurídica denominado Constituição que, no ordenamento jurídico, se localizava acima da vontade pessoal do governante**, representando a “certidão de nascimento” de um novo Estado. É um pacto social que constitui uma nova nação. Este movimento histórico que elevou a Constituição ao documento jurídico mais importante de um Estado recebeu o nome de “**constitucionalismo**”. **Os marcos históricos do constitucionalismo moderno são a constituição americana de 1787 e a constituição francesa de 1791.**

Reparem nas datas: constituição americana de 1787 (poucos anos após a declaração de independência dos Estados Unidos frente à Inglaterra em 1776) e constituição francesa de 1791 (poucos anos após a Revolução Francesa de 1789). Isso indica que, após uma grande ruptura social (geralmente por meio de uma revolução), o primeiro documento a ser elaborado pelo **poder constituinte originário** é uma nova Constituição, que deve conter, basicamente, a estrutura de poder do novo Estado e de suas instituições, a previsão de direitos e garantias fundamentais e o regime de governo.

No Estado Liberal é que foram difundidos os chamados **direitos humanos de primeira dimensão (também chamados de direitos civis e políticos, de direitos de defesa ou de direitos de liberdade do indivíduo frente ao Estado)**. Eles já existiam desde a origem humana (como foi afirmado no início do texto), porém se tornaram especialmente conhecidos nesta época. Isto porque, nesta época do liberalismo (final do século XVIII), o ser humano tinha por objetivo se proteger da interferência indevida do Estado em sua vida. Justamente por estar “traumatizado” com o regime anterior (absolutismo), no qual o rei abusava do poder estatal, o ser humano objetivou difundir direitos que o protegessem deste abuso. Daí se dizer que, em seu nascedouro, **os direitos humanos visavam conter o abuso do poder estatal.**

Os direitos humanos de primeira dimensão têm por característica exigirem uma **ABSTENÇÃO, uma omissão do Estado**, não no sentido de o Estado não fazer nada para o indivíduo ter o seu direito efetivado (se fosse assim, os

² CF, art. 1º, Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

governantes mais relapsos seriam os mais virtuosos). **A omissão aqui é no sentido de o Estado não tomar nenhuma conduta que possa atrapalhar a fruição e o exercício daquele direito.** Ex.: para o indivíduo ter o seu direito à vida efetivado, o Estado não pode matá-lo injustamente; para o indivíduo ter o seu direito ao voto preservado, o Estado não pode impedi-lo de exercer este direito etc. Percebam que são direitos que exigem que o Estado “**não**” faça algo, no sentido de não atrapalhar. Logo, também são chamados de “**direitos negativos**”. Na Constituição Federal brasileira de 1988, são os direitos constantes no **artigo 5º**: direito à vida, à integridade física, ao voto, acesso ao Poder Judiciário etc.

Porém, nem todas as conquistas do Estado Liberal foram positivas. Afastar o Estado da vida dos indivíduos tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo.

Isto porque como os indivíduos pediram ao Estado para se “afastar” das suas vidas, o Estado se sentiu “incentivado” a não intervir na vida dos indivíduos ainda que fosse para beneficiá-los. Como exemplo, podemos afirmar que, naquela época, não se falava em direitos sociais (educação, saúde, previdência etc), mesmo porque o Estado se sentiu “estimulado” a não interferir na vida dos indivíduos ainda que fosse para ajudá-los. No Estado Liberal do século XVIII, cumpriria ao Estado apenas quatro funções: manter um exército (para protegê-lo contra invasões externas), manter uma polícia (para aplacar conflitos internos), manter um corpo diplomático (para discutir assuntos com outros Estados) e manter o Poder Judiciário (para resolver as lides entre os particulares).

Desta maneira, se antes víamos no Estado Absolutista o abuso do poder estatal, no Estado Liberal passamos a ver o abuso do poder econômico (de um indivíduo para com o outro), afinal, onde o poder político (do Estado) não controla, o poder econômico (dos particulares) tende a prevalecer. Reparem que o poder político e o poder econômico estão em lados opostos da balança, um controlando o outro.

Obviamente, esta situação também gerou insatisfação na população. O fato de agora não ser mais o Estado quem lhe oprime (mas sim outro indivíduo particular) não acalmou os ânimos da sociedade.

Não se pode esquecer que, neste contexto, estava inserida a primeira Revolução Industrial (aproximadamente de 1760 a 1850), período no qual as condições de trabalho eram precárias, com baixos salários, gerando crescente insatisfação popular. Até então, não se falava em direitos trabalhistas (típicos direitos sociais), pois o Estado não se intrometia nas relações entre particulares (seja para o bem, seja para o mal, conforme já exposto). Justamente por esta falta de intromissão do Estado nas vidas das pessoas é que os contratos de trabalho de crianças e jovens eram considerados **lícitos** nesta época. Não havia nenhum problema jurídico no fato de uma criança de nove anos firmar um contrato de trabalho com o dono de uma carvoaria.

Com uma sociedade cada vez mais cansada da exploração de um indivíduo por outro é que se começou o movimento pela implantação dos chamados **direitos sociais, também conhecidos por direitos humanos de segunda dimensão**. Enquanto os direitos humanos de primeira dimensão objetivavam uma ABSTENÇÃO do Estado (no sentido de não atrapalhar a fruição de direitos dos indivíduos), **os direitos humanos de segunda dimensão visavam a um AGIR do Estado**, na busca por uma maior **igualdade material** dos indivíduos (igualdade no mundo real, que é diferente da igualdade jurídica – igualdade perante a lei).

Aliado a isso, tem-se o surgimento do movimento socialista dos trabalhadores no século XIX, clamando por mais direitos sociais. Este cenário de ebulição social tornou-se propício à positivação dos direitos sociais na **Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição de Weimar (Alemanha) em 1919**, sendo as primeiras Constituições ocidentais que previram alguns direitos trabalhistas. Tais Constituições são consideradas os **marcos históricos do denominado Estado Social**, que sucedeu o antigo Estado Liberal. **Por meio do Estado Social, admite-se uma intervenção do Estado na vida dos indivíduos para trazer-lhes uma maior igualdade material (igualdade real entre as pessoas, sem tanta diferença socioeconômica).**

Conforme dito anteriormente, os direitos sociais (ao contrário dos direitos de liberdade) exigem um agir, um fazer estatal. Não basta mais a inércia do Estado (no sentido de não atrapalhar o exercício de um direito, como era em relação aos direitos de liberdade). Agora, o Estado deve ter uma conduta comissiva (um fazer). Desta maneira, para o indivíduo ter o seu direito à educação efetivado, deve o Estado construir escolas, contratar professores etc; para o indivíduo ter o seu direito à saúde preservado, deve o Estado construir hospitais, contratar médicos e enfermeiros etc. Em suma, para efetivar os direitos sociais, o Estado deve ter condutas proativas. Por exigirem que o Estado “faça algo”, os direitos sociais são também conhecidos como **“direitos positivos”**. Na Constituição Federal brasileira de 1988, são os artigos constantes **no artigo 6º**: direito ao trabalho, ao transporte, à moradia, à previdência, à saúde, à educação etc³.

Nesta altura da explicação, o leitor pode estar pensando que com a efetivação dos direitos humanos de primeira e de segunda dimensões o indivíduo já está com sua dignidade humana preservada, correto? Errado. Isso porque um conhecido evento de proporções mundiais (a Segunda Guerra Mundial) extirpou a ideia de que bastava ao indivíduo ter direitos humanos de primeira e de segunda dimensões para ter a sua dignidade humana preservada. Imagine o seguinte exemplo: um indivíduo francês de classe média, vivendo na década de 1940 na França, tinha seu direito à vida (primeira dimensão) e ao trabalho (segunda dimensão) preservados. Porém, com a invasão da França pela Alemanha, este indivíduo foi expulso de sua residência pela tropa alemã, tendo

³ CF, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

de fugir para não ser morto. Pergunta-se: nesta situação, a dignidade humana dele está preservada? Obviamente que não.

Com isso queremos dizer que especialmente após a segunda guerra mundial, começou-se a falar sobre os **direitos humanos de terceira dimensão**, que são os direitos dos seres humanos enquanto membros da humanidade (também chamados de **direitos de fraternidade**). Verificou-se que o ser humano faz parte de um grupo maior do que o grupo formado por pessoas do seu bairro, da sua cidade ou do seu país: o ser humano faz parte da humanidade (aldeia global) e, como tal, deve possuir direitos que o protejam neste sentido. **São os chamados direitos difusos**, que possuem este nome justamente por estarem difundidos (espalhados) pela sociedade. São exemplos o direito ambiental, direito à comunicação, direito à preservação do patrimônio da humanidade etc.

Assim, para se ter a dignidade humana preservada, devem ser conjugados os direitos das três dimensões: **a proteção do indivíduo isolado (liberdade - primeira dimensão)**, **a proteção do indivíduo em relação aos seus pares (igualdade material – segunda dimensão)** e **a proteção do indivíduo enquanto membro da humanidade (fraternidade - terceira dimensão)**. As três camadas de proteção de direitos dos indivíduos formam o **lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade**. Somente com a existência concomitante destas três camadas de proteção é que podemos falar em **dignidade da pessoa humana (tratar o indivíduo como um fim em si mesmo, e não como meio para a satisfação de outros seres humanos, segundo a clássica lição de Immanuel Kant)**. Por isso, de uma maneira geral, a doutrina prefere a utilização do termo “**dimensão**” de direitos ao termo “**geração**”: “geração” pode causar a falsa percepção de que o direito posterior substituiu o direito da geração anterior, o que não é verdade. O direito de terceira dimensão não substituiu o direito de segunda e nem este substituiu o direito de primeira. Em verdade, para a dignidade humana ser preservada, os três direitos devem coexistir, ou seja, estarem presentes **AO MESMO TEMPO** na vida do indivíduo⁴ (interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos).

Outra modificação advinda após a segunda guerra mundial foi a **substituição do positivismo clássico pelo neoconstitucionalismo**. Explica-se: ao final da segunda guerra mundial, vários soldados e oficiais do exército alemão foram presos, sob acusação de crimes de guerra. Ao serem interrogados, sempre se defendiam alegando não terem cometido “nenhum ato ilícito”, porque, em verdade, eram “forçados” a matar os inimigos, já que esta era a lei alemã da época. Portanto, como soldados do exército alemão, não lhes restaria outra alternativa a não ser “cumprir a lei”, ainda que contra a sua vontade. Por isso havia (e ainda há) o argumento de que o positivismo jurídico foi utilizado indevidamente como justificativa jurídica para o regime nazista.

⁴ Paulo Bonavides ainda fala na existência de uma quarta dimensão de direitos humanos, que seriam os direitos necessários à concretização de uma sociedade aberta para o futuro, a exemplo do direito à democracia e ao pluralismo. Porém, pelo fato de sua aceitação doutrinária não ser uniforme, preferimos apenas nos referir ao conceito tradicional de três dimensões de direitos humanos.

Este argumento não foi aceito, especialmente no Tribunal de Nuremberg (1945/1946). O estrito cumprimento da lei pelos soldados nazistas que recebiam ordens dos seus superiores, não justificava a ofensa aos direitos humanos perpetrada contra milhões de pessoas. Ao contrário do que constava na chamada Teoria Pura do Direito (de Hans Kelsen), **o Direito não deve ser analisado sem a influência de outras ciências igualmente importantes, como a filosofia, a sociologia, a psicologia, a economia etc.** Da mesma maneira, **a lei não deve ser analisada isoladamente, pois ela é parte de um todo maior denominado sistema jurídico que, por sua vez, também faz parte de um sistema maior denominado sistema social (Niklas Luhmann).** Vale ressaltar que o trabalho de Kelsen foi muito importante à época para conferir de vez a autonomia da ciência jurídica; porém, a interpretação de sua obra foi equivocadamente utilizada para justificar as atrocidades nazistas praticadas contra milhões de pessoas, sob o singelo argumento de que “o soldado estava apenas cumprindo a lei”.

Nesta época (logo após a segunda guerra mundial), o conceito de **princípio jurídico** não era tão difundido. Na década de 1940, a palavra “princípio” não era dotada de um sentido específico na área jurídica: ela possuía um sentido comum, de sua própria etimologia, que significa “introdução”, “começo” de algo. Assim, se um jurista escrevesse um livro na década de 1940 com o título “Princípios de Direito Civil”, ele queria, em verdade, dizer que aquele era um livro “introdutório” de direito civil, o “começo” do direito civil, ou seja, suas lições iniciais.

Porém, hoje em dia, **“princípio” é considerado espécie do gênero “norma jurídica”, ao lado das “regras”.** Melhor explicando: **norma jurídica é o gênero do qual decorrem as espécies “princípios” e “regras”.**

A **norma jurídica** é uma ordem normativa da conduta humana. É o Estado determinando como alguém pode ou não se comportar.

Os **princípios jurídicos** são proposições genéricas, mais abstratas que as regras, que incorporam dentro do Direito os valores sociais existentes. Exemplo: um dos valores existentes na sociedade atual é a “honestidade”. A sociedade preza por uma pessoa honesta. Ao inserirmos este valor “honestidade” dentro do Direito (tecnicamente, ao **juridicizarmos** a honestidade), ela acaba recebendo o nome de “princípio da probidade”. Portanto, princípios são valores sociais juridicizados (incluídos no Direito, para terem valor jurídico). São aplicáveis na **“maior medida possível”**, ou seja, quanto mais princípios o jurista conseguir aplicar em um caso concreto, melhor será. O conflito entre princípios é resolvido pelo **método da ponderação**: um princípio cede em relação a outro, até ambos se harmonizarem no caso concreto, sem que um seja “anulado” para sempre naquele caso. Os princípios são também chamados de **“mandamentos de otimização”**, pois buscam se otimizar/harmonizar na maior medida possível.

Já as **regras** são proposições normativas mais específicas, que visam a concretizar os princípios. Elas tornam os princípios aplicáveis na prática (trazem

densidade aos princípios). São aplicáveis aos casos concretos sob a técnica do **“tudo ou nada”**, isto é, ou se aplica a regra a determinado caso ou não se aplica. Exemplo: um indivíduo desferiu uma facada em outro: ou ele agiu com o ânimo de matar (e aí se aplica a regra do artigo 121 do código penal - homicídio) ou ele agiu com a intenção de ferir (o que incidiria a regra do artigo 129 do código penal – lesão corporal). Ao se descobrir a intenção do agente (se matar ou ferir), o juiz decidirá pela regra aplicável ao caso concreto (se a regra aplicável será do artigo 121 ou 129 do código penal).

E o que isso tem a ver com o neoconstitucionalismo?

Antes de responder à pergunta, vamos retomar o raciocínio.

Neste resumo, já foi dito que o constitucionalismo foi o movimento histórico pelo qual a constituição foi erigida (elevada) ao documento mais importante do ordenamento jurídico de um Estado. A vontade do rei foi substituída pela vontade do povo (novo titular do poder estatal), expressa por meio da Constituição e das leis.

Logo após a Revolução Francesa, o Poder Judiciário na Europa não gozava de tanta independência, pois a sociedade da época temia que o Poder Judiciário, por meio de interpretações “elásticas” da lei, favorecesse a retomada da monarquia. **Por isso a interpretação legal mais difundida na época era a interpretação literal: o juiz deveria ser a “boca da lei” (*la bouche de la loi*).**

Especialmente após as atrocidades da segunda guerra mundial, verificou-se que interpretar uma lei apenas sob o aspecto formalista (a lei é válida?) poderia legitimar qualquer vontade política travestida sob a forma de lei.

Agora, sob a teoria do **neoconstitucionalismo**, o Direito deve ser interpretado com base na supremacia e centralidade da Constituição, (1) limitando os poderes estatais e (2) interpretando a ciência jurídica tendo por ponto de partida os direitos fundamentais.

Portanto, **o neoconstitucionalismo surge como um movimento histórico pós-positivista, em especial na segunda metade do século XX, com o objetivo de conferir maior eficácia às normas constitucionais, partindo-se da interpretação constitucional para se alcançar a exegese da norma jurídica, inclusive mediante a análise de princípios jurídicos explícitos e implícitos.** Neste novo modelo de Estado Constitucional de direito, há uma reaproximação do Direito e da Justiça (ao contrário do sustentado pela Teoria Pura do Direito), com uma **força normativa da Constituição e dos princípios jurídicos**, de modo que o antigo argumento de que o soldado “apenas está cumprindo a lei” não mais se sustenta.

Com a força normativa da Constituição surge, inclusive, **o direito subjetivo de exigir a implementação de direitos sociais**, afinal, se a Constituição tem força normativa (premissa maior) e considerando que os direitos sociais estão previstos constitucionalmente (premissa menor), resta

clara a possibilidade de exigí-los, seja na via administrativa ou judicial (conclusão do silogismo).

Assim, **hoje em dia é plenamente possível se exigir a efetivação dos direitos sociais, inclusive os chamados direitos da seguridade social** (art. 194, CF), que compreende o conjunto de ações do Poder Público e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à previdência social, assistência social e saúde (método mnemônico “**PAS**”: **P**revidência, **A**ssistência e **S**aúde.). Justamente por isso, diuturnamente milhares de ações são propostas em face do INSS, objetivando a implantação de direitos sociais previdenciários e assistenciais. Aqui é o ponto de contato com a disciplina de Direito Previdenciário.

A força normativa da constituição é que permite, também, a internalização dos direitos humanos no ordenamento jurídico de um país.

Como já dito aqui, os direitos humanos são direitos inerentes a qualquer ser humano, pelo simples fato de ter nascido (direitos inatos). São previstos em tratados e convenções internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. **Quando estes direitos humanos são internalizados no ordenamento de um país (geralmente por meio de sua Constituição), eles passam a se chamar “direitos fundamentais”.** Vale dizer: **os direitos fundamentais nada mais são do que “direitos humanos constitucionalizados”.** Em seu conteúdo, direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa (tecnicamente, possuem a mesma natureza jurídica): ambos visam a concretizar a dignidade da pessoa humana. **Eles se diferem apenas em seu âmbito de previsão: enquanto os direitos humanos estão previstos em documentos/tratados internacionais, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição de um Estado.** A semelhança entre eles é tanta que há doutrinadores que utilizam as expressões “direitos humanos fundamentais” ou “direitos fundamentais humanos” como sinônimos.

Enfim, creio que dessa maneira conseguimos estudar, em apenas 8 páginas, quase 300 anos de história dos direitos humanos, passando pelos principais conceitos do Direito Constitucional e ainda fazendo a interlocução com o Direito Administrativo e o Direito Previdenciário, o que será muito útil em futuro Exame da OAB ou mesmo em concurso público para as diferentes carreiras jurídicas.

Deixo aqui registrado meu agradecimento.

Prof. Wilson José Vinci Júnior